

1500114-51.2021.8.26.0187

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas. Ambas moravam na mesma residência. A Polícia havia recebido denúncias de que elas praticavam o vil comércio e haviam assumido o "ponto" de tráfico que era do traficante conhecido como "Japonês", marido de BRUNA. Assim, ao avistarem ELAINE na data dos fatos, os Policiais Militares resolveram abordá-la. Na ocasião, ELAINE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Centro - CEP 18870-000, Fone: (14) 3382-1855,

Fartura-SP - E-mail: fartura@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500114-51.2021.8.26.0187

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2042424/2021 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 16216536 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 190/21/108 -

DEL.POL.TAQUARITUBA, 2042424 - DEL.POL.TAGUAI, 190/21/108 - DEL.POL.TAGUAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

17/02/2022

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade e Comarca de Fartura, Estado de São Paulo, na sala virtual de audiência, presente o MM. Juiz Substituto desta Comarca, Exmo. Sr. Dr. Mário Henrique Gebran Schirmer, comigo Escrevente Técnico Judiciário, no final nomeado e assinado, aí, após os pregões legais, verificou-se o comparecimento do DD. Promotor de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Pedro Rafael Nogueira Guimarães, da ré Elaine Cristina de Oliveira, acompanhada do seu defensor Dr. Saed Zanardo Miranda; da ré Bruna Estefani Macário, acompanhada de seu defensor Janio Irone Bergamo. Instalada a audiência, a ré Bruna foi

interrogada, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Em seguida, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e perguntado às partes se havia algum requerimento de diligências, nos termos do artigo 402 do CPP, sendo que não houve qualquer requerimento, passando-se então aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi feita a seguinte manifestação, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. A seguir, foi dada a palavra ao Dr. Defensor da ré Bruna, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Na sequência, foi dada a palavra ao Dr. Defensor da ré Elaine, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Posteriormente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Trata-se de AÇÃO PENA ajuizada pelo Ministério Público do Estado São Paulo em desfavor de ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA e BRUNA ESTÉFANI MACÁRIO, já qualificadas nos autos, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06

A denúncia foi apresentada nos seguintes termos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em data incerta, porém, anterior ao dia 14 de fevereiro de 2021, cidade de Taguaí, nesta Comarca de Fartura, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, qualificada às fls. 13/14, e BRUNA ESTÉFANI MACÁRIO, qualificada às fls. 23/24, associaram-se para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, qualificada às fls. 13/14, e BRUNA ESTÉFANI MACÁRIO, qualificada às fls. 23/24, colocando em prática dos fins para os quais fora constituída referida organização, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 18,5 gramas (dezoito gramas e cinco centigramas) de maconha (Cannabis sativa L.), e 62,7g (sessenta e dois gramas e sete centigramas) de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 07/09, auto de constatação preliminar às fls. 10/11e laudo de exame químico-toxicológico a ser juntado aos autos. Ao que se apurou, as denunciadas ELAINE e BRUNA se associaram para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas. Ambas moravam na mesma residência. A Polícia havia recebido denúncias de que elas praticavam o vil comércio e haviam assumido o "ponto" de tráfico que era do traficante conhecido como "Japonês", marido de BRUNA. Assim, ao avistarem ELAINE na data dos fatos, os Policiais Militares resolveram abordá-la. Na ocasião, ELAINE trazia consigo uma sacola contendo diversas embalagens plásticas utilizadas na partilha e embalado de drogas. Os Policiais ainda notaram que ela apresentava um volume no interior do sutiã. Instada, ELAINE retirou do sutiã uma porção de cocaína, uma balança de precisão e R\$ 95,15 em espécie. Ato contínuo, dirigiram-se à residência das autoras, local em que se encontrava BRUNA. Realizadas buscas, no quarto de BRUNA,

em cima de uma penteadeira, encontraram duas porções de maconha. Assim, ambas foram presas em flagrante delito. Considerando as denúncias prévias, somadas à quantidade de entorpecentes e forma de acondicionamento, apreensão de petrechos utilizados na partilha da droga e de dinheiro, resta evidente que os entorpecentes se destinavam ao vil comércio” (fls. 195-196).

Foi proferida decisão convertendo as prisões em flagrante preventivas (fls. 75-77). As acusadas apresentaram resposta à acusação (fls. 271-272; 280).

Foi deferida a liberdade provisória da acusada Elaine (fls. 284-287).

Foi proferida decisão (fls.329-332) recebendo a denúncia, e designando audiência de instrução, debates e julgamentos, sendo realizada de maneira semi-presencial diante das diversas providências para redução da disseminação do novo Coronavírus - Covid - 19, conforme Provimento 2556/2020 de 07/05/2020.

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas, bem como a inquirição das acusadas, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020.

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou, em síntese, pela parcial procedência da pretensão punitiva. Após tecer considerações sobre as provas, argumentou que devida a absolvição em relação ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, em relação a ambas as acusadas, desclassificação da imputação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei de Drogas, em relação a acusada Bruna, e a condenação da acusada Elaine pela prática do crime do art. 33, da Lei 11.343/06. A respeito da dosimetria da pena, sustentou que devida a valoração desfavorável dos vetores de natureza e quantidade; na segunda fase o reconhecimento de confissão espontânea; inexistência de causa de diminuição; postulou pela fixação de regime inicial fechado; inaplicabilidade do art. 44 e art. 77, do CP; e perdas dos valores apreendidos.

A defesa de Bruna, por sua vez, apresentou alegações finais sustentando que inexistem provas suficientes à condenação. Alegou, subsidiariamente, que devida a desclassificação, em relação a imputação do art. 33, caput, para o art. 28, ambos da Lei de Drogas.

A Defesa de Elaine sustentou, em síntese, que devida a absolvição do art. 35, da Lei de Drogas, a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente.

Por esta razão, é possível analisar o mérito da pretensão punitiva.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência de fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de

condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório. Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática dos delitos imputados às rés.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 07-09), autos de constatação preliminar (fls. 10 e 11) laudos periciais (fls. 300-302; 303-305; 306-309; 310-312), bem como pela prova oral produzida em juízo e em fase de inquérito.

4. Passo à análise da autoria.

A testemunha Marcos (policial) narrou, em síntese, que avisaram a acusada Elaine, tendo notado que ela tinha algo na mão. Disse que existiam várias informações implicando Elaine na prática do tráfico de drogas. Afirmou que este objeto que era possível ver em posse da acusada seria um saquinho de sorvete, usado para embalar drogas, e, também, dava para ver também que ela tinha algo na blusa. Relatou que os objetos que estavam nas vestes a acusada eram: uma porção de cocaína (60g), uma balança de precisão e um pouco de dinheiro. Diante da abordagem e das informações, mediante autorização, direcionaram-se à casa das acusadas (que moram juntas), no onde localizaram duas porções de maconha no total de 20g. Disse que existam também informações de que a acusada estava associada a Bruna no tráfico. Explicou que Bruna seria a companheira da pessoa identificada por 'japonês', que foi preso por tráfico. A respeito da droga encontrada na casa, Bruna teria dito que era usuária. Então, conduziram as acusadas à Delegacia. Especificou que a maconha foi encontrada somente na casa, com a Bruna, e a balança, com a Elaine, em seu sutiã - no qual também estava escondida uma porção de cocaína. Esclareceu que Bruna e Elaine residiam juntas e a pessoa identificada como 'japonês' em outra casa. Disse que existiam várias informações implicando as acusadas na traficância, especialmente após a prisão de 'japonês', sendo que as informações eram de que as acusadas teriam assumido sua posição. Disse que ambas as acusadas teriam negado a traficância, tendo Bruna dito que a maconha seria para uso próprio.

A testemunha Ricardo (policial) disse que estava em patrulhamento, juntamente com o policial Marcos, pela Av. Castelo Branco, quando viram a acusada Elaine com uma sacola plástica na mão e, em razão de informações anteriores a respeito de suposta traficância da acusada, decidiram proceder com a abordagem. Informou que com Elaine foi encontrado cocaína e uma balança de precisão. Em seguida, considerando os bens encontrados em posse da acusada e as informações anteriores, foram à casa da acusada Elaine (que também é casa da acusada Bruna, pois elas moravam juntas), e no local encontraram duas porções de maconha. Disse que não recorda se as acusadas apresentaram versões sobre os fatos. Esclareceu que existiam várias informações de que as acusadas estariam praticando a traficância, sendo que estas informações eram via de regra informais, porque realizadas por informantes que não gostariam de se identificar. Relatou que as informações davam conta de que as acusadas teriam assumido a traficância anteriormente realizada por uma pessoa identificada como japonês, que fora preso anteriormente. Afirmou que os direitos das acusadas foram respeitados no momento da abordagem. Disse que Bruna estava na casa no momento da busca. Esclareceu que Bruna não foi presa em flagrante anteriormente, mas quando a pessoa de japonês foi preso, Bruna residia com ele.

Em seu interrogatório, a acusada Elaine disse que no dia dos fatos realmente estava em posse das drogas. Afirmou que, no entanto, seu único vínculo com Bruna é o fato de que moram juntas. Disse que iria 'manusear a droga'. Descreveu os fatos como 'uma besteira'. Afirmou que nunca viu Bruna usar droga. Relatou que não tem conhecimento sobre a maconha encontrada. Disse que pegou a droga 10min antes da abordagem. Afirmou que conheceu a Bruna um mês antes de serem presas. Relatou que estava procurando alguém para dividir as despesas da casa e morou somente 08 dias junto com Bruna. Disse que somente moravam juntas e não tem grande amizade, tendo conhecido Bruna somente porque ela residia perto da casa da avó da depoente. Disse

ser usuária de cocaína e não saber se Bruna usa drogas. Afirmou que pegou a droga em um bar, após ter sido ofertado para que realizasse o tráfico. Desconhece a razão da existência de resquícios de maconha na balança de precisão. Afirmou que não conhecia os policiais anteriormente e que eles não teriam razão para lhe incriminar injustamente. Disse que no momento em que moraram juntas não notou nada que implicasse a acusada Bruna com a traficância. Confessou que estava praticando o tráfico de drogas. Esclareceu que seus direitos foram lidos e respeitados durante a abordagem policial.

Em juízo, a ré Bruna negou a traficância. Especificamente, disse que praticava o tráfico e não sabia que Elaine vendia drogas. Confirmou que a maconha apreendida em sua casa era de sua propriedade, mas alegou que a droga era para consumo pessoal. Disse que morava com Elaine apenas a 8 dias. Afirmou que resolveram morar juntas, porque ambas recém separadas. Disse que se conheciam há algum tempo, embora não fossem amigas antes de morar juntas. Disse que usa maconha, mas não utiliza outras drogas. Afirmou que não assumiu o 'ponto' de tráfico de japonês, tendo, inclusive, separado dele, em razão de sua traficância pretérita.

5. Diante deste cenário, entendo que ficaram comprovadas autorias e materialidades do delito de tráfico.

No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que os policiais militares narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que eles tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa aos acusados. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento dos fatos, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas. Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico ao de outras pessoais quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória.

É que pelas versões apresentadas é possível concluir, para além de dúvida razoável, que a acusada Elaine foi surpreendida, em via pública, em posse de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro, com a intenção de realizar o tráfico de drogas, conforme confessado pela própria acusada. Ademais, na casa em que as acusadas moravam foram encontradas também duas porções de maconha, que seriam de Bruna. Neste contexto, observe-se que os policiais apresentaram versões claras, harmoniosas e verossímeis dos fatos, apontando, sempre, as acusadas como autoras do

delito. Ademais, a narrativa é acompanhada das demais provas dos autos, até mesmo a confissão de Elaine. A respeito da participação de Bruna, entendo que igualmente confirmada. Note-se que Bruna, mesmo quando da abordagem, admitiu que a droga encontrada na casa seria sua. Já por este motivo, nota-se que a controvérsia não reside na autoria, mas na tipicidade da ação. Ademais, os policiais narraram que a droga encontrada na casa (maconha) efetivamente seria de Bruna, tendo ela admitido ser proprietária da droga.

Dessa maneira, entendo que estão comprovadas autoria e materialidade da conduta descrita na exordial.

6. Passo à análise do tipo penal.

6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: “Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. (grifo nosso).

In casu, em relação a conduta praticada pela acusada Elaine a situação, inequivocamente, atraía a incidência do tipo penal previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. A própria acusada confessou não somente que trazia consigo a porção de cocaína objeto dos autos, mas que efetivamente pretendia vender o entorpecente, após aceitar uma proposta anterior que lhe tinha sido feita para a comercialização. Nesse sentido, sua conduta adequa-se aos núcleos: “traze consigo”, “guardar” e “expor a venda”.

6.1.1. Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, entendo ser cabível, em relação a acusada Elaine, dado que a ré é primária (fl. 54), não ficou comprovado que ela se dedique a atividades criminosas ou tampouco que integra organização criminosa, o que autoriza a aplicação da cláusula de 'tráfico privilegiado'.

6.1.2. In casu, não restou devidamente comprovado que a acusada Bruna possuísse as drogas para distribuição a terceiros, havendo, pois, 'dúvida razoável' a respeito da efetiva ocorrência sobre a traficância. Isto porque, considerando as frágeis circunstâncias que, em tese, indicariam o acusado como sendo 'traficante' e a pequena quantidade de drogas, é, ao menos, possível considerar a hipótese de que as drogas apreendidas fossem, efetivamente, para consumo pessoal.

É dizer: embora o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, apresente um tipo plurinuclear alternativo, faz-se necessária a comprovação do dolo na prática da traficância – isto é, a demonstração de que o agir nuclear do tipo se orienta pela finalidade do cometido do ato de tráfico de drogas. Tal situação não restou demonstrada nos autos.

Portanto, devida a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei 11.343/06.

6.1.2.1. No ponto, ressalvo meu entendimento pessoal, no sentido que a tipificação estabelecida no art. 28, da Lei 11.343/06, padece de inconstitucionalidade, na medida em que, em decorrência do princípio da lesividade/ofensividade penal – o qual decorre diretamente do direito de liberdade, previsto no art. 5º, caput, e X, da CF –, é incompatível com a ordem constitucional a criminalização de condutas que não atinjam bens jurídicos de terceiros.

É que, conforme bem expôs John Stuart Mill, em seu célebre ensaio Sobre a Liberdade: “só o dano para os interesses de outros – ou a probabilidade elevada de haver dano – pode justificar a interferência da sociedade” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almedina/Saraiva, 2011, p. 86).

“Nenhuma pessoa devia ser punida simplesmente por estar bêbada; mas um soldado ou um polícia devia ser punido por estar bêbado em serviço. Resumindo: sempre que há

um dano claro, ou um risco claro de dano, quer para um indivíduo quer para o público, o caso é retirado do campo da liberdade e colocado no da moralidade ou da lei.

Mas em relação ao dano meramente contingente ou, como pode ser chamado, estrutural, que uma pessoa causa à sociedade através de conduta que nem viola qualquer dever específico para com o público, nem dá azo a danos perceptíveis para qualquer indivíduo definido senão ela mesma, a sociedade pode dar-se ao luxo de suportar essa inconveniência, tendo em vista o bem maior da liberdade humana. Se fosse para punir adultos por não tomarem bem conta de si, preferia que fosse para seu próprio bem, e não com o falso pretexto de os impedir de diminuir a sua capacidade de prestar à sociedade benefícios que esta não finge ter o direito de exigir. Mas não posso aceitar discutir o assunto como se a sociedade não tivesse quaisquer outros meios de elevar os seus membros mais fracos ao padrão normal da conduta racional, a não ser esperar que fizessem algo irracional, e depois puni-los, legal ou moralmente, por isso.” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almeidina/Saraiva, 2011, p. 77).

A posição não é distinta na doutrina jurídica.

Conforme exposto, pelo Prof. Salo de Carvalho, em sua tese de mestrado, A Política Criminal de Drogas no Brasil:

“O princípio da lesividade ou da ofensividade complementa, de forma organizativa, o princípio da intervenção mínima. O princípio dispõe que somente poderá ser aplicada penalidade no momento em que a ação infrinja bem jurídico determinado, produzindo-lhe dano - resultado material. Quatro funções específicas são delineadas pelo princípio da lesividade, segundo Nilo Batista: a. proibição de incriminações de atitudes internas; b. proibição de criminalizar condutas que não excedam o âmbito do próprio autor; c. proibição de incriminações de simples estados ou condições existenciais; e, d. proibição de criminalização de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico específico. [...].

Sobre a incriminação de atos que não excedam o próprio autor, o princípio se refere à proibição de incriminação de autolesões, crimes impossíveis e atos preparatórios. Relativo ao caso das drogas, toma-se questão fundamental a análise do bem jurídico tutelado e a potencialidade da lesão, principalmente nas condutas usuais.”

(CARVALHO, Salo. A Política de Drogas no Brasil, dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito da UFSC, 1996, p. 108-109 - negrito original, grifos próprios).

Também nesse sentido:

“A despeito da importância dada por alguns autores funcionalistas ao conceito de bem jurídico para a afirmação da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal, a existência e tutela penal do bem jurídico somente tem importância se esse conceito for considerado em conjunto com a ofensividade mínima que se exige para a caracterização da tipicidade material do delito (ZAFFARONI, et all., 2010, p. 212). [...].

Em face do princípio da lesividade ao bem jurídico, para E. Raúl Zaffaroni, são ilegítimas incriminações penais que imponham uma determinada moral ou que tenham conteúdo simbólico (ZAFFARONI, et all., 2010, p. 221). Postula também a ilegitimidade do uso da legislação penal a situações em que, embora absolutamente ineficaz para os resultados a que se destina, talvez até mesmo agravando-os, o legislador utiliza-a para tranquilizar a opinião pública e de este modo, proveer al clientelismo político (ZAFFARONI, et all., 2002, p. 489).

Nesse sentido, é de reconhecer-se como função da ofensividade a limitação ao Poder Legislativo, uma vez que devem ser consideradas inconstitucionais as intervenções penais que criminalizam condutas que não ofendem ou sequer geram perigo concreto de lesão a bens jurídicos.

Esses limites impostos ao legislador quando da incriminação de condutas foram sistematizados por Nilo Batista, ao afirmar que o princípio da lesividade tem as seguintes funções: a) proibir a incriminação de uma atitude interna; b) proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor; c) proibir a

incriminação de simples estados ou condições existenciais; e d) proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetam qualquer bem jurídico, tendo-se por desviada a conduta fortemente desaprovada pela coletividade (BATISTA, 1999, p. 92 e ss).

De fato, não se pode deixar de constatar a inconstitucionalidade de intervenções estatais desse jaez, na medida em que a Constituição consagra o direito à liberdade de opinião e de expressão (art. 5º, IV, VI), a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X) e o pluralismo político e social (art. 3º, IV).

Assim, manifesta-se a inconstitucionalidade de intervenções estatais com tais conteúdos na medida em que reduzem direitos fundamentais, sem que qualquer finalidade social possa ser antevista nessas intervenções. As intervenções estatais são inconstitucionais se não tiverem por finalidade assegurar os objetivos da República Federativa do Brasil expressos no art. 3º da CR/88. Pelo contrário, o que se vislumbra em incriminações sem ofensa a bens jurídicos é que elas não apenas distanciam a sociedade brasileira de uma sociedade livre (art. 3º, I, CR/88) como ainda ampliam a marginalização, que é objetivo estatal eliminar (art. 3º, III, CR/88). Não se pode perder de vista que: O mais importante compromisso vinculador da atuação do Estado brasileiro decorrente da natureza de nossa Constituição (pacto social) é o reconhecimento da existência de um núcleo inviolável de direitos, constituído pelos direitos fundamentais, cuja tutela é prioridade máxima do Estado e que não podem ser suprimidos nem mesmo a pretexto de atender à vontade da ampla maioria ou ao consenso existente na sociedade. (BRODT, 2005, p. 33)." (ÂREDE, Sirlene Nunes. O Princípio da Ofensividade e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in: Revista CEJ, Brasília, Ano XV, n. 55, p. 36-45, out./dez. 2011, p. 37-38).

Além disso, não se pode olvidar que tramita, perante o Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário (RE 635659), com questão de repercussão geral reconhecida, em que se discute a constitucionalidade da previsão normativa do art. 28, da Lei 11.343/06.

É certo que o caso ainda está pendente de julgamento definitivo. Porém, é igualmente inequívoco que os Ministros Gilmar Mendes (relator), Luís Roberto Barroso e Edson Fachin já proferiram votos no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade.

Neste contexto, transcreve-se trecho paradigmático do voto do Ministro Relator: "Nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Deles pode-se extrair o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação.

A proteção do indivíduo contra interferências que se estimem indevidas por parte do Estado pode ser atalhada, dessa forma, com a invocação do princípio da liberdade geral, que não tolera restrições à autonomia da vontade que não sejam necessárias para alguma finalidade de raiz constitucional, e mesmo pelo apelo ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que pressupõe o reconhecimento de uma margem de autonomia do indivíduo, tão larga quanto possível, no quadro dos diversos valores constitucionais.

É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação.

O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita.

Esses efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação é excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para consumo pessoal dependeria, assim, da validade da incriminação da autolesão. E a autolesão é criminalmente irrelevante. São ilustrativos, nesse sentido, os exemplos citados por DANIEL PRADO (Boletim, IBCRIM, outubro/2012, p. 8-9), verbis: [...].

A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à ofensa à privacidade e à intimidade do usuário. Está-se a desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em

risco a própria saúde.

Não chego ao ponto de afirmar que exista um direito a se entorpecer irrestritamente. É perfeitamente válida a imposição de condições e restrições ao uso de determinadas substâncias, não havendo que se falar, portanto, nesse caso, em direito subjetivo irrestrito. Cabe registrar que, com esse mesmo entendimento, a Corte Constitucional alemã negou, em 1994, no julgamento do caso Cannabis, a existência de semelhante direito (Recht zum Rausch), afirmando, com isso, a viabilidade da criminalização do tráfico de cannabis sativa (BverfGE 90,145, 9.3.1994).

Também explicitou que o art. 2, I, da Lei Fundamental alemã, assegura o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, mas que o uso de drogas, em especial graças à forte repercussão social que tem, não pode estar nele incluído. Não haveria, assim, um direito a “ficar intoxicado” (“Recht auf Rausch”) assegurado pela Lei Fundamental.

O Tribunal considerou, todavia, que casos envolvendo posse, compra ou importação de pequenas quantidades de maconha para uso eventual devem ser desconsiderados pela insignificância de culpa e da proporção do dano causado.

De forma resumida, o §31 da lei alemã sobre narcóticos (“Betäubungsmittelgesetz”) estabelece que a posse de pequenas quantias de drogas pode não ser criminalizada, exceto em caso de interesse público, e autoriza os promotores a encerrar o caso sem consultar o Judiciário.

Ainda que se afirme que a posse de drogas para uso pessoal não integra, em sua plenitude, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, isso não legitima que se lance mão do direito penal para o controle do consumo de drogas, em prejuízo de tantas outras medidas de natureza não penal, como, por exemplo, a proibição de consumo em lugares públicos, a limitação de quantidade compatível com o uso pessoal, a proibição administrativa de certas drogas sob pena de sanções administrativas, entre outras providências não tão drásticas e de questionáveis efeitos como as sanções de natureza penal.

Na Espanha, por exemplo, entre as sanções administrativas previstas na legislação, há multas de até 30 mil euros e/ou a suspensão da carteira de motorista. São medidas, como se percebe, bem mais eficazes na contenção do consumo do que a simples aplicação de medidas penais sem resultados práticos demonstráveis.

Dessa forma, a prevenção do uso indevido de drogas, um dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas – art. 4º da Lei 11.343/06 – é uma finalidade estatal válida e pode ser alcançada, com maior eficácia, por meio de um vasto leque de medidas administrativas.

Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade.

Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção social, como prevê nossa legislação – arts. 18 e seguintes da Lei 11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua inserção social.

A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal. Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além de mera lesão pessoal.

Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional.” (Voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, no RE 635659 – grifos próprios).

Não distinto foi o posicionamento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso:

“VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A DESCRIMINALIZAÇÃO

Do ponto de vista jurídico, há pelo menos três fundamentos que justificam e legitimam a descriminalização à luz da Constituição:

1. Violação ao direito de privacidade

A intimidade e a vida privada, que compõem o conteúdo do direito de privacidade, são direitos fundamentais protegidos pelo art. 5º, X da Constituição. O direito de privacidade identifica um espaço na vida das pessoas que deve ser imune a interferências externas, seja de outros indivíduos, seja do Estado. O que uma pessoa faz na sua intimidade, da sua religião aos seus hábitos pessoais, como regra devem ficar na sua esfera de decisão e discricionariedade. Sobretudo, quando não afetar a esfera jurídica de um terceiro.

Ex. É preciso não confundir moral com direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas que nem por isso são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, bebe até cair desmaiado na cama, isso não parece bom, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, tampouco parece bom, mas não é ilícito. Pois digo eu: o mesmo vale se, em lugar de beber ou consumir cigarros, ele fumar um baseado. É ruim, mas não é papel do Estado se imiscuir nessa área.

2. Violação à autonomia individual

A liberdade é um valor essencial nas sociedades democráticas. Não sendo, todavia, absoluta, ela pode ser restringida pela lei. Porém, a liberdade possui um núcleo essencial e intangível, que é a autonomia individual. Emanação da dignidade humana, a autonomia assegura ao indivíduo a sua autodeterminação, o direito de fazer as suas escolhas existenciais de acordo com as suas próprias concepções do bem e do bom. Cada um é feliz à sua maneira. A autonomia é a parte da liberdade que não pode ser suprimida pelo Estado ou pela sociedade.

Exs mais óbvios: o Estado e a sociedade não podem decidir com quem você vai se casar, qual deve ser a sua religião ou que profissão você vai seguir.

As pessoas têm, igualmente, o direito de escolher os seus prazeres legítimos. Há quem faça alpinismo, voe de ultraleve, participe de corridas de automóvel, ande de motocicleta ou faça mergulho submarino. Todas essas são atividades que envolvem riscos. Nem por isso são proibidas. O Estado pode, porém, limitar a liberdade individual para proteger direitos de terceiros ou determinados valores sociais. Pois bem: o indivíduo que fuma um cigarro de maconha na sua casa ou em outro ambiente privado não viola direitos de terceiros. Tampouco fere qualquer valor social. Nem mesmo a saúde pública, salvo em um sentido muito vago e remoto. Se este fosse um fundamento para proibição, o consumo de álcool deveria ser banido. E, por boas razões, não se cogita disso.

Note-se bem: o Estado tem todo o direito de combater o uso, fazer campanhas contra, educar e advertir a população. Mas punir com o direito penal é uma forma de autoritarismo e paternalismo que impede o indivíduo de fazer suas escolhas existenciais. Para poupar a pessoa do risco, o Estado vive a vida dela. Não parece uma boa ideia.

3. Violação ao princípio da proporcionalidade

O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, na sua dimensão instrumental, funciona como um limites às restrições dos direitos fundamentais. Para que a restrição a um direito seja legítima, ela precisa ser proporcional. Em matéria penal, tal ideia se expressa em alguns conceitos específicos, que incluem a lesividade da conduta incriminada, a vedação do excesso e a proibição da proteção deficiente.

O denominado princípio da lesividade exige que a conduta tipificada como crime constitua ofensa a bem jurídico alheio. De modo que se a conduta em questão não extrapola o âmbito individual, o Estado não pode atuar pela criminalização. O principal bem jurídico lesado pelo consumo de maconha é a própria saúde individual do usuário, e não um bem jurídico alheio. Aplicando a mesma lógica, o Estado não pune a tentativa de suicídio ou a autolesão. Há quem invoque a saúde pública como bem jurídico violado. Em primeiro lugar, tratar-se-ia de uma lesão vaga, remota, provavelmente em menor escala do que, por exemplo, o álcool ou o tabaco. Em segundo

lugar porque, como se procurou demonstrar, a criminalização termina por afastar o usuário do sistema de saúde, pelo risco e pelo estigma. De modo que pessoas que poderiam obter tratamento e se curar, acabam não tendo acesso a ele. O efeito, portanto, é inverso. Portanto, não havendo lesão a bem jurídico alheio, a criminalização do consumo de maconha não se afigura legítima. O teste da proporcionalidade inclui, também, a verificação da adequação, necessidade e proveito da medida restritiva. A criminalização, no entanto, não parece adequada ao fim visado, que seria a proteção da saúde pública. Não apenas porque os números revelam que a medida não tem sido eficaz – o consumo de drogas ilícitas, inclusive da maconha, tem aumentado significativamente –, como pelas razões expostas acima: a saúde pública não só não é protegida como é de certa forma afetada pela criminalização.

A questão da necessidade poderia ser disputada. Há países que optam por criminalizar a maconha. Mas em número decrescente. Na América Latina, como visto, somente Brasil, Suriname e Guianas tratam o porte de drogas para uso pessoal como crime. Existem alternativas que vão desde a previsão de sanções administrativas até o combate via contrapropaganda e cláusulas de advertência.

Mas é sobretudo no terceiro subprincípio – o da proporcionalidade em sentido estrito –, quando se vai aferir o custo benefício da criminalização que a desproporcionalidade se evidencia de maneira mais contundente. O custo tem sido imenso – em recursos drenados para a repressão, para o sistema penitenciário, nas vidas de jovens que são destruídas no cárcere, no poder do tráfico sobre as comunidades carentes – e os resultados têm sido pífios: aumento constante do consumo.

Em suma: por ausência de lesividade a bem jurídico alheio, por inadequação, discutível necessidade e, sobretudo, pelo custo imenso em troca de benefícios irrelevantes, a criminalização não é a forma mais razoável e proporcional de se lidar com o problema.

Pelos mesmos fundamentos, declaro a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 1º do artigo 28 da Lei n 11.343/2006, o qual prevê que se submete às mesmas penas do caput, “quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica”. Aqui, à falta de um critério específico para delimitar o que seja pequena quantidade para consumo pessoal, utilizo o parâmetro adotado no Uruguai, que é de 6 (seis) plantas fêmeas.” (Voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no RE 635659 – negritos originais, grifos próprios).

Entretanto, é fato que não existem precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06. Ao contrário, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a constitucionalidade da norma supracitada. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Sentença que desclassificou a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas e reconheceu sua inconstitucionalidade – Recurso Ministerial – De rigor a inversão do decísum – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 1500247-53.2021.8.26.0556; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021).

“Apelação criminal – Porte de drogas para uso próprio – Juizado Especial de origem que declinou sua competência para a Justiça Comum de Primeiro Grau, diante da impossibilidade de localização do réu – Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade, seja por inconstitucionalidade do art. 28, da Lei de Drogas, ou por aplicação do dito 'princípio da insignificância'. Ausência de recurso Ministerial. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – apreensão de 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) – Acusado que, na fase extrajudicial, assumiu a posse do entorpecente, não tendo

comparecido em Juízo, onde foi decretada a sua revelia - Depoimento seguro do Policial Militar em Juízo confirmando a localização de entorpecentes na residência do réu - De rigor a manutenção da condenação pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal. 'Princípio da insignificância' - Impossibilidade de reconhecimento - Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Inconstitucionalidade não reconhecida - conduta despenalizada, mas que permanece criminalizada pela Lei nº 11.343/06. Dosimetria - Patamar das penas de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa que não comporta reparos, especialmente em face da reincidência advinda de tráfico privilegiado. Recurso Defensivo desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1500668-61.2018.8.26.0099; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021).

"Posse de maconha - Insignificância do ato - Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Inexistência - Condenação mantida; Furto qualificado - Escalada - Ausência de laudo pericial - Não caracterização - Inteligência do art. 158, do Código de Processo Penal; Furto - Multirreincidência - Confissão - Preponderância da agravante sobre a atenuante - Impossibilidade - Compensação integral - Não cabimento - Recurso provido em parte para redução da pena." (TJSP; Apelação Criminal 1501253-43.2020.8.26.0617; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021).

Portanto, considerando os reiterados julgados do e. TJ-SP reconhecendo a constitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06, bem como considerando que ainda está pendente de julgamento definitivo, - a despeito de votos já proferidos - o RE 635659, que tramita no Supremo Tribunal Federal, ressalvo meu entendimento pessoal e deixo de reconhecer a inconstitucionalidade da previsão normativa em comento.

6.2. A norma penal prevista no art. 35, da Lei 11.343/06, expõe como típica a conduta de "Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei".

Conquanto o texto normativo determine como típica a conduta, independente de reiteração, a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido que a 'estabilidade e permanência' são imprescindíveis. Por todos, veja-se:

"1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes." (RHC 108.003/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

No ponto, a jurisprudência destaca, ainda, que os requisitos de 'estabilidade e permanência', exigidos para a configuração do delito do art. 35, da Lei 11.343/06, são distintos do elemento de reiteração - este sim dispensado.

"1.5. A estabilidade e permanência, que são elementares do crime de associação para o tráfico, não se confundem com a habitualidade ou reiteração criminosa. 1.6. Inexiste bis in idem em razão do não reconhecimento do crime continuado, pela habitualidade criminosa, e ainda, a condenação pelo delito de associação para o tráfico." (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).

Nesse sentido, o que se verifica é que para a configuração do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, faz-se necessário demonstrar que a associação para o tráfico preenche os requisitos de 'estabilidade e permanência' - requisitos que, note-se, também são exigidos para a configuração do crime do art. 288, do CP (associação criminosa) -, prescindindo, no entanto, da comprovação de reiteração. Em outras palavras: a conduta do art. 35, da Lei 11.343/06, é típica, ainda que cometida uma única vez (ausência de reiteração), desde que demonstrada a 'estabilidade e permanência'.

No ponto, destaque-se que a exigência de estabilidade e permanência não ofende ao princípio da legalidade. Ao contrário, somente afirma uma diferença normativa e ontológica entre os art. 29, do CP (concurso de pessoas) e o tipo do art. 35, da Lei 11.343/06 (ou, para tais fins, também do art. 288, do CP). Afinal, há uma distinção essencial – reconhecida pelo legislador, sendo, portanto, também normativa – entre o cometimento de um delito juntamente com outro agente (art. 29, do CP – concurso de pessoas) e a associação para o cometimento de delitos (art. 35, da Lei 11.343/06 e art. 288, do CP). Esta distinção é, justamente, a 'estabilidade e permanência'.

In casu, embora existam indícios de que as acusadas pudessem estar associadas na prática da traficância, tal hipótese não restou suficientemente demonstrada. Isto porque, embora os policiais tenham afirmado que existiam informações de que as acusadas estariam associadas para a prática do tráfico de drogas, não foram apresentadas informações